
제59회 변리사 2차 시험

특허법 해설

안녕하십니까.

제59회 변리사 제2차 시험 특허법 답안을 업로드합니다.

올해 특이점은 ① PCT 5년 주기가 깨진 점, ② 무권리자 특허 판례 및 일사부재리 판단 시점 관련 문제가 2년 연속으로 출제된 점, ③ 특이발명인 의약용도발명이 출제된 점, ④ 절차조치 문제가 없고 최근 판례 문제 비중이 높은 점 등에 있습니다.

난이도는 사람마다 다를 수 있지만, 절차조치 문제가 없고 최근 판례 문제 비중이 높은 점에 비추어 다른 해에 비해 다소 평이한 편으로 생각됩니다.

각자 노력하신 만큼 좋은 결과를 얻으시길 바랍니다.

모두 고생 많으셨습니다.

(주)한빛지적소유권센터

특허법 강사 일동 배상

[문제-1]

I. 설문(1)

(1) 이 사건 계약의 이행이 완료된 후, 甲은 이 사건 발명을 특허청에 출원하였다. 이 사건 발명에 관한 권리귀속을 토대로 甲의 이 사건 발명의 출원이 적법한지를 판단하시오. (10점)

1. 권리귀속 판단

(1) 관련 규정

- ① 발명자주의 (法 제33조 제1항 본문)
- ② 특허를 받을 수 있는 권리의 이전 (法 제37조 제1항)
- ③ 출원의 효력 : 대항요건 (法 제38조 제1항)

(2) 관련 판례 - 영업양도 判例 (+@)

영업양도는 채권계약이므로 양도인이 영업양도계약에 따라 재산을 이전할 때에는 포괄승계가 인정되지 않고 특정승계의 방법에 의하여 재산의 종류에 따라 개별적으로 이전행위를 하여야 한다.¹⁾

(3) 사안

- ① 원시적 귀속주체 : 甲의 종업원 (발명자)
- ② 중간 양도인 : 甲 (종업원으로부터 승계)
- ③ 권리 귀속주체 : 乙 (영업양도 특정승계 + 출원은 대항요건 → 특발권 이전 유효)

2. 출원이 적법한지

(1) 관련 규정 - 출원인 적격 (法 제33조 제1항 본문)

(2) 관련 판례 - 중간 양수인 사건 判例

특허출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리를 계약에 따라 이전한 양도인은 더 이상 그 권리의 귀속주체가 아니므로 그러한 양도인이 한 특허출원에 대하여 설정등록이 이루어진 특허권은 특허무효사유에 해당하는 무권리자의 특허이다.²⁾

(3) 사안

중간 양도인 甲 → 더 이상 권리 귀속주체 X

→ 무권리자 출원 (法 제33조 제1항 본문 위반) : 부적법

1) 대법원 2020. 8. 27. 선고 2019다225255 판결: 당해 판례 사건은 영업양도 + 포괄승계 방식으로 특허권 이전의 효력이 없다고 하였지만, 본 문제의 사실관계에서는 영업양도 + 특정승계 방식으로 특발권 및 특허권 이전의 효력이 있다고 봄이 타당.

2) 대법원 2020. 5. 14. 선고 2020후10087 판결

II. 설문(2)

(2) 이 사건 계약의 이행이 완료된 후, 乙은 특허권 이전의 등록 없이 이 사건 특허를 실시하고 있다. 이에 甲은 乙의 이 사건 특허의 실시가 자신의 특허권을 침해하는 것이라고 주장한다. 이 사건 특허에 관한 권리귀속을 토대로 특허권 침해 여부에 대해 판단하시오. (10점)

1. 권리귀속 판단

(1) 관련 규정

- ① 특허권 이전 (法 제99조 제1항)
- ② 등록의 효력 : 효력발생요건 (法 제101조 제1항)

(2) 사안

영업양도 특정승계, but 이전등록 X → 특허권 이전 무효

권리귀속 주체 : 甲 (특허권 양도인)

2. 특허권 침해 여부

(1) 관련 판례 - 영업양도 判例

피고회사가 원고회사와 이 사건 계약을 체결함으로써 이 사건 특허발명들에 관한 특허권을 포함하여 그 특허권실시의 기초가 되는 영업재산을 일체로 양수하였고, 그 대금을 원고회사에 모두 지급한 사실은 앞서 본 바와 같으므로, 피고회사가 비록 특허권이전등록을 마치지 아니하였다고 하더라도 이 사건 계약의 효력으로서 이 사건 특허발명들에 관한 특허권을 실시할 권리가 생긴 것으로 보아야 한다.³⁾⁴⁾

(2) 검토

통상실시권 계약은 명시 또는 묵시적으로도 가능하며, 특허권을 이전하기로 하는 계약에는 그 상대방에게 더 이상 그 특허권을 행사하지 않겠다는 내용이 당연히 전제되어 있다고 볼 수 있으므로, 타당하다.

(3) 사안

미등록 특허권 양수인 乙 : 통상실시권자 → 특허권 침해 X

[정확히는, 특허권 침해 O, but 정당권원 O]

+@ 신의칙 위반 여지

3) 앞의 대법원 2020. 8. 27. 선고 2019다225255 판결의 원심 특허법원 2019. 3. 15. 선고 2018나1558 판결

4) 2012나88954 : 피상속인은 쟁점양수도계약 체결 당시 000 등에게 피상속인의 상표권을 포함한 영업 일체를 양도하였다고 추인함이 타당하다. 그러므로 비록 그 후 000가 피상속인의 상표권에 관하여 이전등록을 하지 않았다고 하더라도 000는 위와 같은 양도계약에 따라 피상속인의 상표를 사용할 정당한 권원이 있다.

Ⅲ. 설문(3)

(3) 특허심사관이 위 (1)에서 수험생이 제시한 결론과 달리 판단하여 특허결정하거나 거절결정 하였다면 어떠한 특허심판을 청구해야 하는지에 대해 설명하고, 청구된 심판이 특허심판원에 계속 중 심판청구인이 동일한 심판을 다시 청구하였다면 특허심판원은 어떠한 판단 또는 조치를 취해야 하는지 설명하시오. (10점)

1. 설문(1)의 결론 (+@)

甲 출원 → 무권리자 출원 (法 제33조 제1항 본문 위반) → 거절결정

2. 어떠한 특허심판을 청구해야 하는지

(1) 관련 규정

무효심판 (法 제133조)

(2) 사안

위와 달리 특허결정을 하였다면, 무효심판을 청구해야 한다.

+@ 이해관계인 : 정당권리자 (法 제133조 제1항 각호)

3. 선행심판 처리 (+@)

적법 → 본안심리 → 인용심결

4. 후행심판 처리

(1) 관련 규정 - 중복심판 (法 제154조 제8항, 민사소송법 제259조 준용)

(2) 요건

① 당사자 동일, ② 심판물 동일, ③ 선행심판 계속 중 후행심판 제기

(3) 판단시점 (+@)

당해심판 심결시

(4) 효과

직권조사사항 + 후행심판 각하심결 (法 제142조)

(5) 사안

① 당사자 동일, ② 심판물 동일, ③ 선행심판 계속 중 후행심판 제기 → 중복심판

→ 각하심결

[+@ if 선행심판 인용심결 확정 후 : 대상 특허권 부존재 → 각하심결]

COMMENT

1. 설문(1)과 설문(2)는 출원 전 특박권 이전의 경우 승계만으로 효력이 발생하지만, 등록 후 특허권 이전의 경우 등록되어야 효력이 발생합니다. 한편, 이 전제로서 영업양도에 따른 특박권 이전 계약 또는 특허권 이전 계약은 유효합니다.
2. 설문(2)에서 미등록 특허권 양수인은 미등록 전용실시권자와 마찬가지로 통상실시권자의 지위를 갖습니다.
3. 설문(3)은 문제 2에서 일사부재리를 출제하고 문제 1의 점수가 일부 부족하여 중복심판 문제를 갑작스럽게 만들어낸 것이 아닐까(?) 추측됩니다.

[문제-2]

I. 설문(1)

(1) 일사부재리에 해당하는지 여부의 판단시점에 관한 대법원 판결로는 「대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결」과 「대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후11360 판결 등」이 있다. 이들 대법원 판결 중 전자는 일사부재리 판단시점을 ‘심판청구시’로 보았고, 후자는 2009후2234 전원합의체 판결을 유지하면서도 또 다른 이유로 일사부재리 판단시점을 ‘심결시’로 보았다. 이들 판례는 모두 유효하다. 이들 판례를 토대로 일사부재리에 해당하는지 여부의 판단시점을 결정하는 판례의 태도를 설명하시오. (10점)

1. 일사부재리 (法 제163조)

- (1) 의의, 취지
- (2) 요건
- (3) 효과

2. 판단시점

- (1) 종래 判例

심결시설

- (2) 전합 判例 (전자 대법원 판결)

종래 판례 → 헌법상 보장된 국민의 재판청구권을 과도하게 침해할 우려 + 심결을 취소한 법원 판결을 무의미하게 하는 불합리 발생

+ 法 제163조 문언해석 → 심판청구시설

- (3) 최근 判例 (후자 대법원 판결)

法 제140조 제2항 → 동일사실 및 동일증거 → 심결시

전합 판례 의미 → 일사부재리 대세효로 인한 제3자 권리 제한 최소화 → 부득이하게 → 일사부재리 요건 中 본안심결 확정의 기준시점만 심판청구시로 변경한 것

[일사부재리 위반 각하심결 취소소송 → 심결시 기준으로 동일사실 및 동일증거를 제출한 것인지 심리 판단하여야 함 (+@)]

3. 결 - 판례의 태도 정리 (+@)

① 동일사실 및 동일증거 → 심결시

② 본안심결 확정의 기준시점 → 심판청구시

II. 설문(2)

(2) 특허법 제163조 단서규정(“다만, 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다.”)의 의의와 본 규정에서 ‘각하심결’로 볼 수 있는 적용범위에 관한 판례의 태도를 설명하시오. (10점)

1. 특허법 제163조 단서규정의 의의

(1) 判例

종래 심판청구의 적법요건을 갖추지 못해 각하된 심결이 확정된 경우에 일사부재리의 효력이 있는지에 관하여 견해대립이 있었으나, 2001년 개정 특허법에서 위 단서 규정을 신설함으로써, 각하심결에 대하여는 일사부재리의 효력이 없음을 명확히 하였다.

(2) 사안

특허법 제163조 단서규정의 의의는 각하심결에 대하여는 일사부재리의 효력이 없음을 명확히 한 것이다.

2. ‘각하심결’로 볼 수 있는 적용범위

(1) 원심 특허법원 判例 (+@)

선행 각하심결은 비록 각하심결이지만 제출된 증거가 선행 확정심결에서 제출된 증거와 동일증거인지 여부를 실체적으로 판단한 것이므로, 위 단서 규정이 적용되지 않는다.

(2) 대법원 判例

1) 문언해석 범위 초과

일사부재리 원칙 위반 각하심결을 본안에 관한 실체심리가 이루어진 기각심결과 동일하게 취급하는 것은 문언의 가능한 해석 범위를 넘어선다.

2) 확장해석 불가

심판청구 남용, 모순·저촉 방지의 일사부재리 제도 취지를 고려하더라도, 심판청구권 보장 역시 중요한 가치인 점, 현행 일사부재리 대세효를 고려할 때 특허법 제163조 단서의 예외를 인정하여 그 적용범위를 확대하는 것은 정당화되기 어렵다.

3) 결론

위 단서 규정은 새로 제출된 증거가 선행 확정 심결을 반복할 수 있을 만큼 유력한 증거인지에 관한 심리·판단이 이루어진 후의 각하심결인 경우에도 동일하게 적용된다.

(3) 검토 (+@)

힘이 센 여자라고 병역의무가 부과되는 것은 아닌 것처럼, 실체적 판단을 한 각하심결이라도 기각심결이 될 수 없다는 점에서, 타당하다.

(4) 사안

① 형식적 판단만 수행된 각하심결 + ② 실체적 판단도 수행된 각하심결 → 모두 특허법 제163조 단서의 각하심결에 해당

COMMENT

1. 문제 2는 최근 판례 문제이며, 문제 스타일을 새롭게 하였지만, 어차피 판례 내용을 적으면 되는 문제로 판단됩니다.
2. 설문 (1) 및 (2) 모두 판례 내용을 적당히 분설하여 기재하면 충분할 것으로 판단됩니다.

[문제-3]

I. 설문(1)

(1) 의약용도발명의 ‘약리기전’ 이 발명의 구성요소로 의미를 가지는 경우를 설명하십시오. (5점)

1. 의약용도발명

특정 물질에 대한 미지의 약리효과 발견에 기초하여 새로운 의약용도를 제공하는 의약발명을 의미한다.

2. 의약용도발명의 구성 判例

의약 물질 + 의약 용도

3. 약리기전 判例

① 약리기전은 특정 물질에 불가분적으로 내재된 속성으로서 특정 물질과 의약용도와의 결합을 도출해내는 계기에 불과하므로, ② 의약용도발명의 청구범위에 기재되어 있는 약리기전은 특정 물질이 가지고 있는 의약용도를 특정하는 한도 내에서만 발명의 구성요소로서 의미를 가질 뿐 약리기전 자체가 청구범위를 한정하는 구성요소라고 보아서는 아니된다.

4. 검토 (+@)

약리기전은 자연법칙 그 자체의 발현에 불과하므로, 타당하다.

5. 사안

청구범위에 약리기전이 기재되고 그 약리기전으로부터 의약용도의 파악이 가능하다면, 그 의약용도를 특정하는 한도 내에서 구성요소로 의미를 가진다.

II. 설문(2)

(2) 발명 X가 위장병 치료 용도로 특허를 받기 위한 진보성 판단 기준을 설명하고, 만일 발명 X의 진보성을 부정하는 경우 선행발명에서 임상시험 등에 의한 치료효과가 확인될 것이 필요한지 설명하십시오. (10점)

1. 발명 X의 성격 (+@)

발명 X는 의약용도발명으로 판단된다.

2. 진보성 - 法 제29조 제2항 (+@)

3. 의약용도발명 진보성 판단 기준 - 判例

의약용도발명에서는 통상의 기술자가 선행발명들로부터 특정 물질의 특정 질병에 대한 치료효과를 쉽게 예측할 수 있는 정도에 불과하다면 진보성이 부정된다.

4. 치료효과 확인이 필요한지 - 判例

선행발명들에서 임상시험 등에 의한 치료효과가 확인될 것까지 요구된다고 볼 수 없다.

5. 선행문헌 결합요건 - 判例 (+@)

6. 사안

(1) 선행발명 1 관련

‘위장병에 선택적 억제제인 X의 시험이 A 연구소에서 다른 세계적인 연구 센터 B와 협력 하에 막 시작되었고 초기 결과는 매우 흥미로워 보인다(very early results look exciting)’는 연구결과 기재는 치료 효과가 있어 흥미롭다는 의미인지 치료 효과가 없어 흥미롭다는 의미인지 불분명하다.

(2) 선행문헌 2 관련

‘X가 위장병 종양의 비정상적 활성의 강력한 억제제이고, 부분적으로 또는 완전히 종양의 치료에 유용할 수도 있다’는 연구결과는 발명 X가 위장병 치료가 나타날 수 있다는 암시, 동기 등을 제시하고 있는 것으로 판단된다.

(3) 결론

선행문헌 1 및 2 모두 발명 X의 위장병 치료 효과에 관한 것으로서 그 기술분야 및 기술적 과제가 동일하고, 그 결합에 어려움이 없다.

통상의 기술자는 선행문헌 1 및 2의 결합으로부터 위장병 치료 효과를 쉽게 예측할 수 있는 정도에 불과하다고 판단된다.

따라서, 임상시험 등에 의해 치료효과가 확인되지 않아도, 발명 X는 진보성이 부정된다.

1. **[선행문헌 결합요건]** 여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단할 때에 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 당해 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)이 쉽게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 당해 특허발명의 진보성은 부정된다(대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결 등 참조).
2. 그리고 **[의약용도발명의 진보성 판단방법]** 의약용도발명에서는 통상의 기술자가 선행발명들로부터 특정 물질의 특정 질병에 대한 치료효과를 쉽게 예측할 수 있는 정도에 불과하다면 그 진보성이 부정되고, 이러한 경우 선행발명들에서 임상시험 등에 의한 치료효과가 확인될 것까지 요구된다고 볼 수 없다.
3. 선행발명 1에는 'GIST에 대해 선택적 티로신 키나제 억제제인 STI571의 시험이 다나-파버 암 연구소에서 다른 세계적인 연구 센터와 협력 하에 막 시작되었고 매우 초기 결과는 흥미로워 보인다(very early results look exciting)'라는 내용의 연구결과가 나타나 있다.
4. 선행발명 2에서 인용하고 있는 선행발명 4에는 '복수의 GIST 환자에게서 5가지 c-kit 유전자 돌연변이가 발견되었고, 이러한 c-kit 유전자 돌연변이를 마우스(mouse)에게 주입하여 동물 실험한 결과 5가지 유형의 c-kit 유전자 돌연변이 모두에게서 정상 마우스와 달리 외부 인자 물질(rmIL-3 또는 rmSCF)이 없이도 Ba/F3 세포의 비정상적인 증식에 따른 종양이 발생하였다'는 내용의 연구결과가 나타나 있다. 선행발명 2는 선행발명 4를 인용하면서 GIST가 c-kit 이상과 관련이 있다는 점을 언급하고 이와 함께 'GIST와 HMC-1 세포주(Human Mast Cell Leukemia)에서 발견되는 c-kit의 비정상적인 활성이 이 사건 의약물질에 해당하는 STI571에 의하여 억제되었음이 HMC-1 세포주에 의하여 확인이 되었다. STI571이 c-kit의 비정상적 활성의 강력한 억제제이고, 세포증식 또는 생존을 위해 c-kit에 부분적으로 또는 완전히 의존하는 종양들의 치료에 유용할 수도 있다는 결론을 내렸다.'라는 내용의 연구결과가 나타나 있다.
5. 위 선행발명들에는 STI571이 c-kit의 비정상적인 활성을 억제함으로써 GIST 치료에 효과가 나타날 수 있다는 암시, 동기 등이 제시되어 있다고 볼 수 있다. 또한 위 선행발명들은 GIST 치료에 관한 것으로 그 기술분야 및 기술적 과제가 동일하고, 그 결합에 어려움이 없으며, 이 사건 의약물질의 GIST 치료용도에 대한 효과도 위 선행발명들로부터 쉽게 예측할 수 있는 정도에 불과하다.
6. 위와 같이 이 사건 제2항 발명의 치료효과를 선행발명들로부터 쉽게 예측할 수 있는 이상 선행발명들에서 임상시험 성공 등에 의하여 치료효과가 확인되지 않아도 이 사건 제2항 발명의 진보성은 부정된다.
7. **사안의 핵심쟁점**은 이 사건 특허발명이 그 출원일 이전에 발표된 학술논문의 "(임상시험의) 아주 초기 결과들이 흥미로워 보인다(very early results look exciting)"는 기재 등으로 인해 이 사건 특허발명의 진보성을 부정할 수 있을 것인지 하는 점이었다. [2019년 지적재산법 중요판례평석, 박성호 교수, 79페이지]

Ⅲ. 설문(3)

(3) 질병 또는 약효와 함께 투여용법과 투여용량을 부가하는 경우, 투여용법과 투여용량이 발명의 구성요소인지 설명하고 새로운 의약품도가 부가되면 특허가 될 수 있는지 설명하시오. (8점)

1. 구성요소 여부

(1) 종래 판례

투여방법은 ① 의료행위에 해당하거나 ② 물건 자체에 관한 것이 아님을 이유로 의약품 발명의 구성요소로 볼 수 없다고 하였다.

(2) 전합 判例 다수의견

① 투여방법은 의약품이 효능을 온전하게 발휘하도록 하여 의약품이라는 물건의 속성 즉, 새로운 '쓰임새'를 제공하므로 '의약품도'와 본질이 같고, ② 투여방법은 약효의 향상이나 부작용의 감소 등과 같이 예상치 못한 효과를 발휘할 수 있고 이에 상당한 비용 등이 소요되므로 이러한 투자의 결과에 대해 특허로서의 보호를 원천적으로 부정하는 것은 특허법의 목적에 부합하지 아니하는 점을 고려하여, ③ (i) 투여방법은 의료행위 자체가 아니라 (ii) '의약품이라는 물건'에 새로운 의미를 부여하는 구성요소가 될 수 있다고 하였다.

(3) 전합 判例 별개의견

① 투여방법은 방법의 성격을 가지며 '의약품도'를 한정하는 것이 아닌 점, ② 투여방법에 특허를 부여하게 되면 의사의 자유로운 의료행위가 제한될 가능성이 있는 점 등을 이유로, 투여방법은 의약품도발명의 구성요소로 볼 수 없다고 하였다.

(4) 검토

① 의약품도발명은 의약품이 효능을 발휘하기 위한 '쓰임새'를 새로이 개발한 것에 '창작성'을 인정하여 특허를 부여하는 것에 그 본질이 있는데, ② '의약품 물질'은 사용상태에 따라 약이 될 수도 있고 독이 될 수도 있으므로, ③ '의약품도'는 의약품이 효능을 발휘하기 위한 쓰임새라는 측면에서 대상 질병 또는 약효뿐만 아니라 투여방법도 포함한다고 볼 수 있는 점 등을 고려할 때, 전합 判例 다수의견이 타당하다.

(5) 사안

질병 또는 약효와 함께 투여용법과 투여용량을 부가하는 경우, 투여용법과 투여용량이 발명의 구성요소다.

2. 특허부여 가부

① 투여용법과 투여용량이라는 새로운 의약품도가 부가되어 신규성과 진보성 등의 특허요건을 갖춘 의약품에 대해서는 새롭게 특허권이 부여될 수 있다.

② 다만, 투여방법의 특허대상성을 인정하는 것이 새로운 투여방법을 개발하기만 하면 곧바로 특허가 부여된다는 것을 의미하는 것은 아니다.

IV. 설문(4)

(4) 발명 Y가 의약품발명의 특정한 투여방법에 관한 진보성을 인정받기 위한 요건을 설명하시오. (7점)

1. 발명 Y의 성격 (+@)

발명 Y는 의약품투여방법 발명으로 판단된다.

2. 진보성 인정 요건 - 대법원 判例

① 의약품개발 과정에서는 약효증대 및 효율적인 투여방법 등의 기술적 과제를 해결하기 위하여 적절한 투여방법과 투여용량을 찾아내려는 노력이 통상적으로 행하여지고 있으므로 ② 투여방법의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 통상의 기술자가 예측할 수 없는 현저하거나 이질적인 효과가 인정되어야 한다.

3. 효과 - 특허법원 判例

투여방법을 통해 진보성이 인정되기 위해서는 예측할 수 없던 약효의 향상, 부작용의 감소, 복약 편의성의 증진 등이 생겨야 한다.

4. 사안

백혈병 치료에서 발명 Y의 경피투여 용법은 전신 경피투여 용법을 사용하면 치료 효과가 오랜 시간 일정하게 지속되어 약효가 향상되고, 간편하게 투약할 수 있는 복약 편의성의 증진이 생긴다.

그리고, 이는 통상의 기술자가 예측할 수 없는 이질적인 효과라 판단된다.

따라서, 발명 Y는 진보성이 부정되지 않는다.

대법원 2017. 8. 29. 선고 2014후2702 판결

통상의 기술자가 비교대상발명들로부터 이 사건 제1항 발명 약학조성물의 경피투여 용도를 쉽게 도출할 수는 없다고 할 것이다. 또한 1979년경부터는 패치 형태의 경피흡수제가 사용되어 왔고, 1986년에 아세틸콜린에스터라제 억제 활성을 가진 피소스티그민을 활성성분으로 하는 전신 경피흡수제가 공지된 바 있다는 사정만으로 이 사건 제1항 발명 약학조성물의 경피흡수성 또한 쉽게 예측된다고 볼 수는 없을 뿐만 아니라, 이 사건 특허발명의 우선일 당시 경피투여용 의약품에 대한 출원 내역이나 기술 수준 등에 비추어 보더라도, 통상의 기술자가 이 사건 제1항 발명 약학조성물의 적절한 투여용법과 투여용량을 찾아내려는 통상적인 노력의 과정에서 경피투여 용도를 쉽게 찾아낼 수 있을 것이라고 볼만한 사정도 보이지 아니한다. 따라서 이 사건 제1항 발명의 경피투여 용도는 출원 당시의 기술수준이나 공지기술 등에 비추어 통상의 기술자가 예측할 수 없는 이질적인 효과라고 보아야 하므로 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정된다고 할 수 없다.

COMMENT

위 판례를 적당히 요약하여 출제한 것으로 판단됨.

[문제-4]

I. 설문(1)

(1) 심결취소소송에서 자백이 가능한 경우를 설명하시오. (6점)

1. 심결취소소송 - 法 제186조 (+@)

2. 적용법규 - 민사소송법 제8조 제2항 (+@)

심결취소소송도 행정소송이며, 민사소송법 준용된다.

3. 변론주의 적용여부 - 判例 (+@)

심결취소소송은 민사소송법 규정이 준용되므로, 변론주의가 지배한다.

행정소송법 제26조는 행정소송의 특수성에서 연유하는 변론주의에 대한 일부 예외규정일 뿐이다.

4. 자백의 구속력 인정가부 - 判例

행정소송인 심결취소소송에서도 원칙적으로 변론주의가 적용되고, 따라서 자백 또는 자백간주도 인정된다고 한다.

5. 자백의 대상 - 判例

자백의 대상은 사실이고, 이러한 사실에 대한 법적 판단 내지 평가는 자백의 대상이 되지 않는다.

6. 자백이 가능한 경우

자백의 대상이 사실인 경우 자백이 가능하다.

II. 설문(2)

(2) 乙이 특허침해소송중 ‘어떤 구성요소를 구비하고 있다’ 라고 한 표현은 재판상 자백인지 설명하고 취소가능한지 설명하시오. (14점)

1. 재판상 자백 (+@)

(1) 요건

① 변론기일 또는 변론준비기일에서 행한 ② 상대방 당사자의 주장과 일치하는 ③ 자기에게 ‘불리’한 ④ ‘사실’의 진술이다.

(2) 효과

① 상대방의 증명책임이 면제되어 증명을 요하지 않으며(민사소송법 제288조 본문), ② 당사자는 임의 철회가 제한되고(민사소송법 제288조 단서), ③ 법원은 자백된 사실을 그대로 인정해야 한다(변론주의).

(3) 취소 요건

① 재심사유 제5호 ② 동의 ③ 반진실 및 착오 ④ 경정의 경우, 자백을 취소할 수 있다.

2. 判例

(1) 침해대상제품 구성 자백

특허침해소송에서 침해대상제품이 어떤 구성요소를 가지고 있는지는 침해판단의 전제가 되는 주요사실로서 재판상 자백의 대상이 될 수 있다.

(2) 종합적 판단

“침해대상제품 등이 어떤 구성요소를 가지고 있다.”는 표현이 사실에 대한 진술인지, 아니면 그 구성요소가 특허발명의 구성요소와 동일 또는 균등하다는 법적 판단 내지 평가에 관한 진술인지는 당사자 진술의 구체적 내용과 경위, 변론의 진행 경과 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

3. 재판상 자백인지

乙은 특허침해소송 제1심 제1회 변론기일에서 제품 Y는 특허발명 X의 구성요소 B를 제외한 나머지 구성요소를 모두 구비하고 있다고 진술하였다. 甲이 제품 Y에 대하여 X의 구성요소 C를 구비하고 있는지 감정신청을 하자 乙은 ‘이 부분에 관하여 다투지 않아 감정이 필요하지 않다’는 의견을 제출하여 甲의 감정신청이 철회되었다.

이후 乙이 제기한 특허발명 X의 등록무효 심판청구 기각심결에 대한 심결취소소송에서 위와 같은 무효사유가 인정되지 않는다는 이유로 청구기각 판결이 내려졌다. 그러자 乙

은 침해소송 제1심 제9회 변론기일에서 구성요소 C에 관한 종전 진술을 번복하였다. 乙은 제품 Y의 구성요소 C 포함 여부에 관한 감정신청을 하였으나, 제10회 변론기일에서 쌍방 모두 감정신청을 하지 않아 변론이 종결되었다.

이와 같은 피고의 진술 내용 및 변론의 진행 경과에 비추어 보면, 침해대상제품이 구성요소 C를 구비하였다는 피고의 진술은, 위 제품의 대응구성이 구성요소 C와 동일 또는 균등한지 등의 법적 판단 내지 평가가 아닌, 구성요소 C 자체를 구비하였다는 사실에 대한 진술로서 재판상 자백이 성립하였다고 봄이 타당하다. 즉, 재판상 자백이다.

4. 자백의 취소가능한지

자백의 취소 요건이 충족되는 사정이 없는 이상, 자백은 취소 불가능하다.

가. 자백의 성립

(1) [침해대상제품 구성 자백] 특허침해소송에서 상대방이 제조하는 제품(이하 '침해대상제품'이라 한다)이 어떤 구성요소를 가지고 있는지는 침해판단의 전제가 되는 주요사실로서 재판상 자백의 대상이 될 수 있다(대법원 2006. 8. 24. 선고 2004후905 판결 등 참조). [종합적 판단] "침해대상제품 등이 어떤 구성요소를 가지고 있다."는 표현이 사실에 대한 진술인지, 아니면 그 구성요소가 특허발명의 구성요소와 동일 또는 균등하다는 법적 판단 내지 평가에 관한 진술인지는 당사자 진술의 구체적 내용과 경위, 변론의 진행 경과 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다. 그리고 [법원 구속력] 일단 재판상 자백이 성립하면 그것이 적법하게 취소되지 않는 한 법원은 이에 구속되므로 법원은 자백과 배치되는 사실을 증거에 의하여 인정할 수 없다(대법원 2018. 10. 4. 선고 2016다41869 판결 등 참조).

(2) 위 법리 및 기록에 비추어 살펴본다.

(가) 피고는 피고의 침해대상제품이 명칭을 "복합 구조물"로 하는 원고의 (특허번호 1 생략) 특허발명(이하 '486 특허'라 한다) 청구범위 제1항(이하 '제1항 발명'이라 한다)을 침해하지 않는다고 주장하면서도, 제1심 제1회 변론기일에서 위 특허발명 중 구성요소 B-2를 제외한 나머지 구성요소를 모두 구비하고 있다고 진술하였다. 원고가 침해대상제품에 대하여 위 특허발명의 구성요소 B-3인 "단부와 최외부 사이의 거리가 평균 막 두께의 10배 이상 10,000배 이하"를 구비하고 있는지에 관하여 감정신청을 하자 피고는 '이 부분에 관하여 다투지 않아 감정이 필요하지 않다'는 의견을 제출하여 원고의 감정신청이 철회되기도 하였다.

(나) 그런데, 피고가 원고를 상대로 486 특허의 기재불비, 신규성 및 진보성 부정 등을 주장하며 제기한 등록무효 심판청구 기각 심결에 대한 심결취소소송에서 위와 같은 무효 사유가 인정되지 않는다는 이유로 청구기각 판결이 내려지자(특허법원 2017. 5. 19. 선고 2016허4948 판결), 피고는 제1심 제9회 변론기일에서 구성요소 B-3에 관한 종전 진술을 번복하였다. 또한 피고는 침해대상제품의 구성요소 B-3 포함 여부에 관한 감정신청을 하였으나, 제10회 변론기일에서 쌍방 모두 감정신청을 하지 않아 변론이 종결되었다.

(다) 이와 같은 피고의 진술 내용 및 변론의 진행 경과에 비추어 보면, 침해대상제품이 구성요소 B-3을 구비하였다는 피고의 진술은, 위 제품의 대응구성이 구성요소 B-3과 동일 또는 균등한지 등의 법적 판단 내지 평가가 아닌, 구성요소 B-3 자체를 구비하였다는 사실에 대한 진술로서 재판상 자백이 성립하였다고 봄이 타당하다.

(3) 그럼에도 원심은, 위 2004후905 판결의 법리를 전제로 침해 물건이 특정 구성요소를 구비하였는지가 사실로서 자백의 대상이 된다고 하면서도, 이 사건에서 피고의 진술은 침해 물건의 어떤 구성요소가 이에 대응하는 특허발명의 특정 구성요소와 동일하거나 균등하다는 법적 판단 내지 평가에 해당한다고 보아 자백이 성립하지 않는다고 ... (중략) ... 잘못 판단하고, 가정적으로 피고의 진술이 자백에 해당한다고 하더라도 피고가 그 자백이 진실에 반하고 착오에 의한 것이라는 이유로 취소하였는데, 제1심에서 이루어진 감정 결과에 의하면 그 자백이 진실에 반하고, 따라서 자백은 적법하게 취소되었다고 판단하였다.

그런데, 제1심에서 이루어진 감정은 침해대상제품이 486 특허 제1항 발명이 아닌(특허번호 2 생략) 특허발명(이하 '395 특허'라 한다) 청구범위 제1, 3항(이하 '제1, 3항 발명'이라 한다)을 침해하는지를 대상으로 한 것이어서 침해대상제품의 평균 막 두께가 측정되지 않았다. 따라서, 위 감정 결과에서 나타난 침해대상제품의 특정 지점들의 두께 편차 범위가, 원고의 486 특허 제1항 발명 침해 주장의 근거이자 피고의 자백의 계기가 된 원고의 자체 실험 결과(갑 제8호증)에 나타난 평균 막 두께 산정의 근거가 된 두께 편차의 범위와 차이가 난다는 점만으로는 그 자백이 진실에 반하는지 여부를 알기 어렵다.

이러한 사정에 비추어 보면, 원심은 그 자백이 진실에 반하는지 여부에 관하여 필요한 심리를 다하지 않은 채 자백이 취소되었다고 판단을 하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.